

宜，借款时孙某某知道所借款项来源于李某某，能够证明孙某某在借款时知晓李某某与彭某间的委托关系。孙某某关于是否知晓李某某与彭某之间存在委托关系的陈述，其在原一、二审和再审中的前后陈述具有不一致性，法院认为其在主观上有故意隐瞒事实之嫌。《中华人民共和国合同法》第四百零三条明确规定了在委托人权益无法保障时委托人的主动介入权。根据该条文意，当受托人因第三人原因对委托人不履行义务时，若委托人原本就知道第三人，便无须受托人告知，更可以直接向第三人主张权利。故本案借款合同直接约束委托人李某某和第三人孙某某。在李某某起诉要求孙某某履行合同义务时，孙某某应当向李某某还款。

综上所述，李某某的再审请求成立，原二审判决错误，北京市第三中级人民法院予以撤销；原一审判决正确，北京市第三中级人民法院予以维持。北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条第一款、第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销本院(2021)京03民终18904号民事判决；
- 二、维持北京市朝阳区人民法院(2020)京0105民初64166号民事判决。

【法官后语】

随着现代社会经济生活方式的进步及多元化发展，无论是民事交易还是商事交易，除少数涉及人身性质的合同外，交易主体都更加关注交易结果而非交易对象，不公开本人身份的代理方式能最大程度上促进物的流通和交易的迅捷。但在实践中严守显名原则不利于纠纷的有效化解。

一、委托人介入权的概念

委托人介入权指的是在受托人与第三人的合同关系中，委托人取代受托人的地位，介入原本是受托人与第三人的合同关系中，享有受托人的权利，承担受托人的义务，是对合同相对性的一种突破。《中华人民共和国民法典》第九百二十五条明确规定了委托人享有介入权。委托人行使介入权的前提是，受托人以自己

的名义与第三人订立合同的事项在委托人的授权范围内，如果合同约定的内容不属于委托人的授权范围，则不具备委托人行使介入权的条件。本案中，李某某

与彭某在合同上附加说明，对具体委托事项作出明确约定，彭某在李某某的授权下向孙某某出借案涉款项，属于委托人的授权范围，因此本案具备委托人行使介入权的条件，李某某有权突破合同相对性原则向孙某某直接主张归还借款。

二、委托人行使介入权的条件

（一）委托关系是否客观存在

有具体的认定标准，书面的委托合同是最直接的认定依据，若无则应从当事人对委托合同的具体履行情况进行判断。本案中，李某某与彭某之间虽未签订书面的委托协议，但彭某与孙某某签订的借款合同上所附的说明对二人之间的委托关系作出了明确约定，并结合其他证据足以认定李某某与彭某之间就案涉款项存在委托关系。

（二）委托人是否具备介入的事由

根据法律规定，委托人介入权行使的事由应在其自身利益受损的情况下，且委托人介入合同应以不使第三人利益受损为限。本案中，一审法院最终支持了李某某的诉讼请求。借款合同中约定的还款期限早已届满，李某某长期向孙某某索要未果，自身权益确已受损，故李某某已经具备了介入彭某与孙某某合同关系的事由。

（三）受托人是否向委托人披露第三人

因受托人以自己的名义实施代理行为，委托人和第三人可能并不知晓对方的确切身份，《中华人民共和国民法典》第九百二十六条明确规定了受托人有向委托人披露第三人的义务，一般来说，受托人应当向委托人履行披露义务，相应地，委托人享有要求其披露的权利。本案中，第三人孙某某关于是否知晓李某某与彭某之间系委托关系在再审和一、二审中的陈述均相互矛盾，彭某虽未明确承认其向委托人李某某披露第三人孙某某，但综合全案证据，有理由相信李某某与孙某某已互相知晓对方身份，李某某可以直接行使介入权，要求孙某某直接向其返还借款本金及利息。

编写人：北京市密云区人民法院 王瑾卿

四、债务偿还认定

33

出借人基于不法原因出借的借款不受法律保护

——冯某诉李某某、许某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泰宁县人民法院(2023)闽0429民初981号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：冯某

被告：李某某、许某某

【基本案情】

冯某与许某某系同学。2022年10月，经许某某介绍，冯某与李某某相识。2022年10月14日，冯某、李某某、许某某相约前往某市，当日三人入住某酒店，于同年11月29日退房。其间，李某某参与当地赌博，冯某多日多次通过银行卡(ATM)取现以及通过微信、支付宝等方式向李某某及案外人转账给李某某出借大额资金。

同年12月29日，李某某、许某某分别在冯某提供的书面借条上的借款人

处及担保人处签字捺印，借条载明：“本人李某某因资金周转需要，兹向冯某借到人民币陆拾叁万捌整(¥638000)，月利率按2%结算。如违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等)均由违约方承担。”落款时间为2022年11月28日。后李某某未按约还款，冯某诉至法院请求：(1)判令李某某归还借款本金638000元及按LPR的四倍标准支付利息；(2)判令李某某承担本案诉讼费用(含律师费、保全费)；(3)判令许某某对上述所有款项承担连带保证责任。

【案件焦点】

冯某请求李某某返还借款是否应得到支持。

【法院裁判要旨】

福建省泰宁县人民法院经审理认为：合法的民间借贷关系应当受到法律的保护，但违反法律或公序良俗的民事法律行为，属于无效行为。案涉借款系冯某明知李某某借款用于赌博仍在赌场上及酒店向其出借资金并收取高额利息的情形下形成的债务，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条“具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效……(四)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的……”的规定，冯某与李某某之间的借贷行为，应认定无效。冯某在明知李某某借款用于赌博的情况下，为获取高额利息仍积极对外出借赌资，既扩大了赌博规模，又变相延长了赌博时间，加重妨碍了社会公共秩序的管理，有违公序良俗和社会主义核心价值观，由此形成的借款系非法债权债务，依法不应得到保护。若本案参照《中华人民共和国民法典》中关于合同无效的规定判令返还借款本金，势必会造成治安管理、刑事司法与民商私法领域之间，就同一问题无法衔接的断层，制造出一种“只要没有被公安机关收缴，出借的赌资依旧可以通过法院追回”的不良法律引导作用，混淆、弱化法律的评价、教育、指导作用，造成国家法律威慑力的下降。

福建省泰宁县人民法院根据《中华人民共和国民法典》第一条、第一百四

十三条、第一百五十三条、第一百五十五条,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百零八条的规定,判决如下:

驳回冯某的全部诉讼请求。

宣判后,双方当事人均未上诉,一审判决生效。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第九百八十五条规定了不当得利制度,除对《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条的文字表述进行调整外,该条还新增了三项请求权的排除事由。尽管在《中华人民共和国民法典》编纂过程中,增补“不法原因给付”作为不当得利请求权的排除事由的呼声较高,但历次草案和《中华人民共和国民法典》的正式文本,都未采纳该意见。“不法原因给付”应如何处理无法律依据,对不法原因之给付能否要求返还,是本案值得研究探讨的重点问题。

一、不法原因给付概念之明晰

“给付”一般是指权利已转移、物已交付、债务已免除等终局性的财货转移的法律行为或事实行为;“给付的原因”应包括目的和动机两者,前者应为给付行为所追求的法律上的目的,后者则是作出给付行为的心理考虑;“不法”的判断依据不外乎是法律的强制性与公序良俗。因此,不法原因给付,是指当事人基于违反强制性法规或公序良俗的原因而为之给付。

二、不法原因给付的处理规则

(一)无效的类型

对于违反法律强制性法规或公序良俗的行为,我国《中华人民共和国民法典》第一百五十三条明确为无效法律行为。

效力性强制性规定的认定有现行法上的条文作为支撑,法官自由裁量范围不是很大。与之相比,抽象性程度更高的公序良俗的认定无疑争议更大,应从行为的反社会性程度进行区分。认定“强反社会性”,需要在具体的案件中对

当事人的动机、目的不法程度进行判定以及决定是否有必要否定其效力。例如，对营业性赌博活动赌资的给付，毫无疑问是与公共道德、风俗习惯相违背的，因此认定为违反公序良俗的“强反社会性”行为是毫无疑问的。

（二）无效的一般后果——不得要求返还

法律行为无效制度是法律对当事人意思自治的干预，对其法律后果的设定必须与制度的适用范围的设置置于同等慎重的地位。而关于违反强行性规定与公序良俗的给付行为无效后的法律后果，主要有不得返还、可得返还等截然不同的处理路径。不得返还作为一般后果，既然当事人选择做出不法原因给付行为，这就表明其置自己于法律与公序良俗的秩序之外，法律对其最好的制裁措施便是让其目的落空，即不允许返还。因此违反强行性规定或公序良俗的不法原因给付行为的法律后果只能是以不返还为基本原则。

（三）无效的例外后果——允许返还

是否允许不法原因给付当事人主张返还，其实质是国家利益与个人利益的平衡问题。在当前我国注重私法自治、注重个人利益的维护的立法背景下，应当适度承认不法原因给付的财产返还请求权。

1. 当不法原因仅存在于受领人一方

在此种情形下，受领人一人之不法，使得给付人为相应的给付，给付人的动机和目的是善良的，是值得被尊重的，其本身不具有可责性，应当得到法律的保护，要求受领人返还其所为之给付，使得其合法之权益能够得到维护。

2. 双方皆不法时的考量

在双方均有不法原因时，法院应当依据现有的证据材料，对双方当事人之间的“不法”作符合比例原则的利益的考量，若给付人的“不法原因”仅是违反管理性强制性规定或者公序良俗之外的一般道德，而受领人违反的是狭义上的强制性规定与公序良俗，则可认为相当于不法原因仅存在于受领人一方，因此给付人仍可主张返还；若给付人之过错更大，则不能支持其返还的请求，能够更大限度地预防不法行为的发生；若双方均有违反效力性的强制性规定与公序良俗的“强反社会性”的动机或目的，给付人均不得主张返还。

3. 损害第三人的合法权益

在很多不法原因给付案件中，当事人之间的给付会损害到第三人的合法权益，主要存在于婚外赠与之中，对于此类情形应认为属于第三人的合法财产当然应当予以返还。

在本案中，冯某作为具有一般社会常识的成年人，势必认识到出借赌资行为的违法性以及该行为会产生的严重后果，但其仍为赚取高额利息向李某某出借赌资，主观动机的不法程度严重，故冯某的行为属于不法原因给付，其对出借款项失去返还请求权，无权要求返还钱款。

编写人：福建省泰宁县人民法院 李吉星 黄雅超

多笔债务清偿顺序的认定标准

——杨某某诉许某甲、许某乙民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市鲤城区人民法院(2023)闽0502民初1684号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：杨某某

被告：许某甲、许某乙

【基本案情】

2016年3月2日，许某甲以资金周转需要向杨某某借款165万元，许某甲出具《借条》，许某乙作为担保人在《借条》上签名盖章，《借条》未约定还

款期限。许某甲依约支付利息。许某甲于2017年2月12日通过银行转账分两笔向杨某某偿还借款本金共计50万元，2017年8月25日偿还借款本金5万元，2018年2月12日偿还借款本金40万元。截至2018年2月12日许某甲结欠杨某某借款本金70万元，并由许某甲在上述《借条》上备注尚欠的借款本金。2018年6月12日，许某甲再次向杨某某借款30万元，加上前期尚欠的本金70万元，截至2018年6月12日，许某甲结欠杨某某借款本金100万元，并由许某甲本人在前述《借条》上予以备注该事实。2021年12月9日，许某甲偿还杨某某借款本金42万元（转至杨某某指定的案外人账户），尚欠杨某某借款本金58万元，并由许某甲本人在前述《借条》上备注该事实，同时杨某某也在《借条》上备注“杨某某同意此备注”。自2022年4月起，许某甲未能足额支付借款利息，每月经支付杨某某利息5800元，最后一次支付利息为2023年1月9日。自2023年1月10日起，许某甲未再向杨某某支付利息，亦未偿还尚欠的借款本金58万元。经杨某某多次催讨，许某甲拒不支付利息及偿还借款本金，许某乙作为担保人在杨某某向其催讨后亦未偿还借款本息。

【案件焦点】

多笔债务到期的清偿顺序认定。

【法院裁判要旨】

福建省泉州市鲤城区人民法院经审理认为：案涉借款合同成立于《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）施行前，但本案有关许某甲还本付息的争议系发生于《民法典》施行后，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二十条规定，该争议应适用《民法典》的相关规定。关于许某甲尚欠的款项，依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条及第三十一条第二款规定，许某甲实际支付利息的超出部分应予以折抵本金，结合许某甲的还款情况，许某甲尚欠的借款本金为426317.02

元。关于许某乙的担保责任，许某乙在案涉《借条》保证人处
签字捺印为案涉165万元借款提供保证责任的时间发生于

《民法典》施行前，应适用当时的法律、司法解释的规定。依照《中华人民共和国担保法》第十九条规定，涉案借条中并未约定保证责任承担方式及保证范围，故许某乙应对许某甲发生于2016年3月2日的165万元的借款本金和利息承担连带保证责任。关于许某甲于2021年12月9日清偿的42万元，该行为发生于《民法典》施行后，依照《民法典》第五百六十条规定，因案涉借款均未约定还款期间，许某甲还款时也未指定清偿顺序，而2018年6月12日的30万元借款缺乏担保，故上述42万元还款应优先抵偿该30万元借款，即许某甲尚欠的款项应是属于2016年3月2日的165万元借款的未清偿部分。故许某乙应对许某甲的上述债务承担连带保证责任。

福建省泉州市鲤城区人民法院判决如下：

一、许某甲应于本判决生效之日起十日内偿还杨某某借款426317.02元，并支付自2023年1月8日起至实际还款之日止按照全国银行间同业拆借中心于2023年2月20日公布的一年期贷款市场报价利率的4倍计算的利息；

二、许某甲应于本判决生效之日起十日内支付杨某某为实现债权支出的律师费7200元；

三、许某乙对本判决第一项、第二项确定的债务承担连带保证责任，许某乙承担保证责任后，有权向许某甲追偿；

四、驳回杨某某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

随着经济高速发展，市场交易愈发频繁，当债务人对同一债权人负有多笔债务，但债务人的给付不足以清偿对同一债权人所负的借款，且未明确偿还的具体借款宗数，双方容易就还款清偿顺序各执己见，因协商不成而转入诉讼程

序。为此，需要确立相对公正、合理、科学的清偿抵充规则。清偿抵充规则直接影响债权人和债务人的切身利益，规则的确立有助于明晰债务清偿的顺序，更好地保护债权人和债务的合法权益，确保市场交易的稳定性。

清偿抵充是指借款人对于同一贷款人负担数笔借款债务，或者负担同一笔

借款债务而约定数次给付时，如果借款人的给付不足以清偿其全额借款债务，约定、决定该给付抵充某笔借款债务的制度。根据《民法典》第五百六十条：“债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同，债务人的给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，由债务人在清偿时指定其履行的债务。债务人未作指定的，应当优先履行已经到期的债务；数项债务均到期的，优先履行对债权人缺乏担保或者担保最少的债务；均无担保或者担保相等的，优先履行债务人负担较重的债务；负担相同的，按照债务到期的先后顺序履行；到期时间相同的，按照债务比例履行。”可见，清偿抵充包括约定抵充、指定抵充和法定抵充三种形式，约定抵充优先，指定抵充次之，最后是法定抵充。

约定抵充即借款人与出借人协商一致，依照双方的意思自治进行抵充。指定抵充是在借款人与出借人未约定时，由债务人在清偿时指定抵充。法定抵充是指当债务人的履行不足以消灭所有债务时，该未足额的清偿中具体指向哪笔债务的问题。具体顺序为：（1）已经到期的债务；（2）缺乏担保或者担保最少的债务；（3）债务人负担较重的债务；（4）先到期的债务，如到期时间一致的，则按照债务比例履行。清偿债务前或清偿债务时未约定抵充、指定抵充时，法定抵充是有益补充，法定抵充体现了诚实信用原则，通过中立的角度，谋求债权人与债务人利益平衡点，相对妥善地对债权人与债务人的利益进行有效安排。

债的清偿抵充问题，长期以来一直是人民法院审判实践的难点问题之一。现实生活中，经常出现债务人对同一债权人负有多项同种类债务。有的已届满，有的未届满；有的附设担保，有的未设定担保；有的设有利息，有的未附利息。《民法典》第五百六十条的规定在一定程度上填补了多债务情形下清偿抵充顺序指定权归属的空白。

编写人：福建省泉州市鲤城区人民法院 柯颖颖

分公司负责人违法以公司名义对外担保，
债权人未尽到必要审查义务担保合同无效

——邱某甲等诉何某等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院(2023)鄂28民
再27号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(再审被申请人、上诉人):邱某甲、邱某乙、邱某丙

原告(再审原告、上诉人):兰某

被告(再审被申请人、被上诉人):何某、冉某

被告(再审申请人、被上诉人):某建设工程公司

【基本案情】

2015年6月30日某建设工程公司分公司成立，贺某为负责人，陈某系该分公司实际控制人。2017年3月1日、3月10日，何某、冉某分两次向邱某(邱某甲、邱某乙、邱某丙之父)借款共计2700万元，贺某、陈某私刻某建设工程公司印章以某建设工程公司的名义为何某、冉某的借款进行连带责任担保，并在借款合同的担保人处加盖了“某建设工程公司”及公司法人“陈某”印章。借款期限届满后何某、冉某未按约还款，邱某遂诉至人民法院。案件审理中邱某病亡，邱某甲、邱某乙、邱某丙以继承人身份继续参加诉讼。在法院组

织调解时，贺某、陈某再次伪造委托书代表某建设工程公司参加调解，并同意对案涉借款承担连带担保责任。执行过程中某建设工程公司提出异议，认为其没有收到诉讼材料，亦未参加调解，同时申请对民间借贷一案进行再审，请求：判决某建设工程公司不承担保证责任。

再审审理中，某建设工程公司向公安机关报案称贺某、陈某伪造公司印章，公安机关予以立案侦查，本案中止审理。

2022年9月5日，陈某因犯伪造公司印章罪，被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元，刑事判决书载明陈某私自以某建设工程公司名义为何某借款提供担保，并在借款合同加盖其伪造的某建设工程公司公章。陈某不服刑事判决提起上诉，二审裁定驳回上诉，维持原判。本案恢复审理后，邱某甲、邱某乙、邱某丙、兰某向法院出具情况说明一份，明确由邱某甲、邱某乙、邱某丙按份平均继承该债权，兰某不参与该债权分配。

【案件焦点】

1. 某建设工程公司是否应对案涉借款承担连带担保责任；2. 陈某在借款合同上加盖印章的行为是否构成表见代理。

【法院裁判要旨】

湖北省利川市人民法院经审理认为：邱某在诉讼中死亡，其继承人作为当事人承担诉讼符合法律规定。当事人对借款金额及利息约定无争议，何某、冉某应偿还借款并支付利息。贺某、陈某未经某建设工程公司授权和许可，私自以某建设工程公司名义为何某、冉某借款提供担保，并在借款合同中加盖了伪造的某建设工程公司公章及法定代表人“陈某”印章，贺某在其中一份2000万元的借款合同中在“法定代表人或委托代理人”栏处签名。贺某的身份仅为某建设工程公司分公司的负责人，在其未取得某建设工程公司的书面授权时，其实施的民事法律行为并不能当然代表某建设工程公司，且公司对外担保需经董事会或者股东会、股东大会决议。债权人在审查公司对外提供担保时，需尽到形式审查的义务，陈某、贺某以某建设工程公司名义对2700万债务提供担保

时，债权人并未审查二人的授权委托书和某建设工程公司的股东会决议，因邱某在提供借款时未尽到形式审查义务，保证合同无效，某建设工程公司对涉案债务不承担连带担保责任。

湖北省利川市人民法院依照《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第二百零六条、第二百一十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第九十九条之规定，作出如下判决：

一、撤销湖北省利川市人民法院(2017)鄂2802民初3790号民事调解书；

二、何某、冉某于本判决生效之日起10日内偿还邱某甲、邱某乙、邱某丙借款本金2700万元，并自2017年9月1日起至2017年9月9日止以2000万元为基数，按照月利率2%支付利息，自2017年9月10日起至还清借款止以2700万元为基数，按照月利率2%支付利息，利随本清；

三、驳回邱某甲、邱某乙、邱某丙的其他诉讼请求。

邱某甲、邱某乙、邱某丙、兰某不服一审判决，提出上诉。湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院经审理认为：邱某未尽到必要审查义务，且陈某的行为不构成表见代理。

湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

公司对外担保是常见的商事行为，但在司法实践中存在大量公司法定代表人、股东、高管未经董事会或股东会决议以公司名义对外担保，分公司未经授权和同意以分公司或者总公司名义对外担保等违规担保行为，在担保合同的签

订上亦存在形式不完备的情形，有的只有法定代表人签名，有的只有公司印章，有的虽加盖了公司印章，但签名者并非法定代表人。本案即分公司未经授权和同意以总公司对外担保的情形。对程序和形式存在问题的公司对外担保效力如何认定，公司是否应当担责是审理这类案件必须解决的问题。

一、《中华人民共和国公司法》第十五条规定的性质

《中华人民共和国公司法》第十五条规定，公司向其他企业投资或为他人提供担保，按照公司章程规定，由董事会或股东会决议。该规定是管理性强制性规定还是效力性强制性规定，在《全国法院民商事审判工作会议纪要》发布之前存在较大分歧，部分法院认定该规定系对公司内部管理行为的规范，不能约束第三人，因此即使未经董事会或股东会决议，对外担保仍有效。《全国法院民商事审判工作会议纪要》发布后，对该规定性质的认定逐渐统一，认为该规定是效力性强制性规定，违反该规定对外担保，除相对人善意外应认定为无效。本案贺某、陈某未经公司董事会或股东会决议以公司名义对外担保，违反了法律的效力性强制性规定，应认定为无效。

二、相对人的合理审查义务

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第七条规定，公司违规担保，相对人善意的，担保有效，并对什么是善意进行了明确，即尽到合理审查义务。由于董事会或股东会决议系公司内部决策行为，相对人不参与公司决策，通常情况下无法核实董事会或股东会决议的真实性，因此相对人在签订担保合同时只需审查是否具有董事会或股东会决议，只要尽到该审查义务，即使决议存在伪造、变造的情形，公司除有证据证明相对人知道或者应当知道决议系伪造、变造外，应承担担保责任。本案在公司担保时邱某并未要求查看董事会或股东会决议，无论公司印章是否伪造，邱某均未尽到合理审查义务。

三、公司对外担保表见代理的认定

《中华人民共和国民法典》第一百七十二条对表见代理作出了明确规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。”表见代理制度不仅要求代理人的无权、越权代理行为在客观上形成具有代理权的表象，而且要求相对人在主观上善意且无过失地相信行为人有代理权，只有在相对人有充分的理由相信行为人具有代理权，且尽到了必要的审查义务的情况下，才构成表见代理。

本案贺某、陈某为分公司人员，并无资格代表总公司实施法律行为，亦从未代表过公司与邱某实施过法律行为，没有证据证明其具有公司代理权，且邱某从未要求贺某、陈某出示过公司授权文件，因此本案不构成表见代理。

四、担保无效的责任承担

无效担保合同的民事责任性质属于缔约过失责任，归责原则采取过错责任原则。担保无效担保人不承担担保责任，但并不意味着担保人不承担责任，在担保无效的情况下需要根据债权人和担保人的过错来确定担保人是否承担赔偿责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第十七条对担保人的赔偿责任作了较为详尽的规定，在主合同有效而担保合同无效的情况下，债权人与担保人均有过错的，担保人承担的赔偿责任不超过债务人不能清偿部分的二分之一；担保人有过错而债权人无过错的，担保人对债务人不能清偿的部分承担赔偿责任；债权人有过错而担保人无过错的，担保人不承担赔偿责任。在主合同无效导致担保合同无效的情况下，担保人无过错的，不承担赔偿责任；担保人有过错的，其承担的赔偿责任不超过债务人不能清偿部分的三分之一。

公司对外担保属于重大事项，涉及公司、股东及债权人多方利益，《中华人民共和国公司法》和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》对此作出了严格的规定，一方面限制了公司法人、高管的权限，其未经法定程序授权并不当然具有代表公司对外担保的权限，旨在防止公司法人、高管违规对外担保，损害公司及中小股东利益；另一方面科以债权人必要的审查义务，债权人不能仅凭公司法人、高管的身份就相信其有代表公司对外担保的权限，防止债权人恶意串通损害公司及第三人利益。通过效力性强制性规定规范公司对外担保，可以规范公司运营和管理，保障公司平稳有效发展，防止公司法人、高管利用管理漏洞损害公司及股东利益，扰乱社会经济秩序，在法律的框架内发挥担保制度的作用。

编写人：湖北省利川市人民法院 冯俊 胡长玖

公司清算组对债权进行核定是诉讼的前置程序

—— 廖某某诉某漆业公司、庄某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省福州市中级人民法院(2023)闽01民再76号民事裁定书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(再审被申请人): 廖某某

被告(再审申请人): 某漆业公司

被告(再审被申请人): 庄某某

【基本案情】

2019年1月4日, 某漆业公司以公司经营资金周转需要为由向廖某某借款200万元, 双方约定借款利息按照月利率2%计付, 借款期限三年。庄某某作为某漆业公司的法定代表人, 自愿为该借款向廖某某承担连带保证责任, 担保期限为三年。借款期内, 某漆业公司给付了截至2021年7月3日的利息, 后续利息未再支付, 借款期满后也未向廖某某履行还款义务。廖某某为此提起诉讼请求还本付息。

【案件焦点】

廖某某的诉请是否符合起诉条件。

【法院裁判要旨】

福建省福州市台江区人民法院经审理认为：某漆业公司向廖某某借款，庄某某对借款债务提供连带责任保证，当事人之间据此订立的民间借贷合同、连带责任保证合同均依法成立，合同合法有效，当事人依法均应履约履行。某漆业公司在借款到期后未按期还款，构成违约，该公司及庄某某依法均应承担违约责任，故廖某某诉讼请求该公司还款付息，以及庄某某对该公司的前述债务负连带保证责任，事实依据成立，于约于法有据；其中原告自愿调低利率，系处分自己的民事权利，不违反法律规定，不损害对方利益，予以照准。两被告经依法送达传票传唤，无正当理由拒不到庭，依法缺席判决。

福建省福州市台江区人民法院判决如下：

一、某漆业公司应于本判决生效之日起十日内，向廖某某一次性偿还借款本金200万元及其利息（该利息自2021年7月4日起按照年利率15.4%计付至实际还款之日止）；

二、庄某某对某漆业公司所负的上述债务承担连带清偿责任。

一审判决生效后，某漆业公司以原判程序违法等为由向福建省福州市中级人民法院申请再审。福建省福州市中级人民法院于2023年3月29日作出民事裁定，提审该案。福建省福州市中级人民法院经再审审理认为：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十二条规定，公司清算时，债权人对清算组核定的债权有异议的，可以要求清算组重新核定。清算组不予重新核定，或者债权人对重新核定的债权仍有异议，债权人以公司为被告向人民法院提起诉讼请求确认的

，人民法院应予受理。廖某某已向某漆业公司清算组申报债权，现提起诉讼不符合法律规定，应驳回起诉。

福建省福州市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第四百零六条规定，裁定如下：

一、撤销福建省福州市台江区人民法院(2022)闽0103民初2887号民事 判决；

二、驳回廖某某的起诉。

【法官后语】

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十二条规定：“公司清算时，债权人对清算组核定的债权有异议的，可以要求清算组重新核定。清算组不予重新核定，或者债权人对重新核定的债权仍有异议，债权人以公司为被告向人民法院提起诉讼请求确认的，人民法院应予受理。”

公司进入清算程序，债权人在向清算组申报债权后，是否仍有权以该债权向人民法院提起诉讼，即上述规定中“清算组不予重新核定，或者债权人对重新核定的债权仍有异议”是否是债权人向人民法院提起诉讼的前置程序，并未有明确规定。有观点认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十二条的规定，并未明确排除债权人向人民法院起诉的权利，经人民法院审理后确定的债权，可以直接列为清算组的核定债权。

再审判决对上述观点进行了澄清，认为公司进入强制清算后，债权人应先依法向清算组申报债权，在清算组未对其债权进行核定前，债权人又向人民法院起诉的，人民法院不予受理，已经受理的应驳回起诉。主要分析如下：

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十一条规定：“公司清算时，清算组应当按照公司法第一百八十五条^①的规定，将公司解散清算事宜书面通知全体已知债权人，并根据公司规模和营业地域范围在全国或者公司注册登记地省级有影响的报纸上进行公告。清算组未按照前款规定履行通知和公告义务，导致债权人未及时申报债权而未获清偿，债权人主张清算组成员对因此造成的损失承担赔偿责任的，人民法院应依法予以支持。”该规定是对《中华人民共和国公司法》第二百三十六关于清算组对债权人清算通知和公告的局限性的补充规定，最大程度上对已知债权人和未知债权人的权益作出保护规定。债权人申报债权后，如清算组对其债权

^①对应2023年12月29日修订的《中华人民共和国公司法》第二百三十五条。

进行核定确认，则该债权无须导入诉讼程序，既能充分发挥公司清算的非讼程序特点，最大程度上减少纠纷，也能减少公司诉累及节约清算成本，将其可能给各方利益主体造成的损失降至最低，有利于推进公司清算顺利进行，符合清算效率原则。

债权人既向清算组申报债权，又就该债权向人民法院起诉的，可能造成管辖权混乱，不利于强制清算工作的开展。《最高人民法院关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要》第三十一条规定，人民法院受理强制清算申请后，就强制清算公司的权利义务产生争议的，应当向受理强制清算申请的人民法院提起诉讼，并由清算组负责人代表清算中公司参加诉讼活动。受理强制清算申请的人民法院对此类案件，可以适用民事诉讼法第三十七条和第三十九条的规定确定审理法院。该纪要确定了向受理强制清算申请的人民法院提起诉讼的基本原则，并对相关管辖权问题作出指引，有利于受理强制清算申请的人民法院统一协调相关清算工作，合理有序调整众多法律主体的利益，维护正常的经济秩序，实现清算程序公正。值得注意的是，上述规定关于管辖权的安排，仍应以《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十二条规定的债权申报为前提，不能理解为排除债权申报前置程序的安排。因此在实践中，发现债权人利用信息差等规避上述管辖权的情况，受理法院应决定不予受理，已经受理的应裁定驳回起诉。

关于强制清算开始前已受理的衍生诉讼的衔接问题。《最高人民法院关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要》第三十条对此作出了安排，即人民法院受理强制清算申请前已经开始，人民法院受理强制清算申请时尚未审结的有关被强制清算公司的民事诉讼，由原受理法院继续审理，但应依法将原法定代表人变更为清算组负责人。实践中，在公司强制清算前，也可能已存在部分债权人提起民事诉讼的情况，基于程序正义的诉讼基本原则的要求，此时应按照上述纪要规定，继续审理，这既是债权申报前置程序的除外情形，也是管辖权的例外安排，符合利益均衡保护原则。

编写人：福建省福州市中级人民法院 纪得军

借款人的借贷行为被认定构成犯罪， 民间借贷合同并不当然无效

——石某某诉梁某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省肇庆市中级人民法院(2023)粤12民终1410号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):石某某

被告(上诉人):梁某

【基本案情】

石某某在未取得建设工程项目的情况下，向梁某称其在广西南宁已取得厕所革命建设两个亿的项目，利用高利回报吸引梁某投资。2020年11月3日，双方签订了《合作投资协议》，约定由梁某投资200000元，月息为3%，期限两个月，到期后未能在两个月内返还应承担利息双倍返还。签订协议后，梁某将200000元转至石某某账户。2021年5月19日，石某某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关依法抓获。2021年9月22日，广东省怀集县人民检察院向该院提起公诉。在该刑事案件审理过程中，石某某的儿子石某甲、石某乙(甲方)于2021年10月28日与梁某(乙方)达成《和解协议》。2021年11月19日，该院作出(2021)粤1224刑初306号刑事判决，判决石某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑，缓刑三年。2022年1月20日，石某某向梁某立下《欠条》，确认欠

梁某利息40000元并承诺分三期还清。后石某某未依约归还欠款，梁某起诉要求石某某归还借款及利息。

【案件焦点】

石某某与梁某之间的借款协议是否有效。

【法院裁判要旨】

广东省怀集县人民法院经审理认为：石某某于2020年11月3日与梁某签订的《合作投资协议》，事后被认定为合同诈骗。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十二条第一款的规定，该《合作投资协议》并不当然无效，认定该协议具有民间借贷合同的效力，应依据《中华人民共和国民法典》及《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》的有关规定处理。《合作投资协议》约定借款期限2个月内月利率3%，逾期利息双倍即月利率6%，均已超出合同成立时一年期贷款市场报价利率3.85%的四倍即15.4%的范围，对超出的部分不予支持。按照实际的借款本金及年利率15.4%计算至1月20日（石某某立下《欠条》之日）石某某尚欠本金97145.55元和利息3401.96元，计至最后一笔还款80000元的2022年1月27日尚欠本金20731元，利息清零。2022年1月28日起石某某应以尚欠本金20731元继续按年利率15.4%计算至付清之日止。广东省怀集县人民法院判决：

一、石某某应归还尚欠本金20731元给梁某，并自2022年1月28日起以尚欠本金20731元按年利率15.4%计算逾期利息，限于该判决生效之日起十五日内付清；

二、驳回梁某的其他诉讼请求。

梁某不服一审判决提起上诉。

广东省肇庆市中级人民法院经审理认为：双方当事人签订的《合作投资协议》虽已被生效判决认定为合同诈骗，但根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十二条第一款的规定，该《合作投资协

议》并不当然无效。梁某作为债权人未主张撤销该协议，双方事后亦签订《和解协议》及《欠条》再次确认双方的民间借贷关系，且刑事判决并未责令石某某向梁某进行退赔，为了更好地保护债权人的合法权益，一审法院认定该协议具有民间借贷合同的效力，依据有关规定处理并无不当，予以确认。综上所述，上诉人石某某的上诉请求不成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，应予维持。广东省肇庆市中级人民法院判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

传统观点认为，借款人在借款时有诈骗等犯罪行为，因此所涉及的民间借贷合同只能认定无效。尤其是在刑事领域，这种观念根深蒂固。从“刑民合一”到“刑民分立”，刑法与民法作为两大基本实体法，在伴随着社会发展的法治进步过程中，各自从不同侧面对社会生活发挥着广泛而深远的调节功能。刑民交叉案件所涉及的民事法律关系是基于行为人的民事行为和经济活动形成的，行为人之间基于合同的约定或依照法律的规定，产生特定的权利义务关系。但在履行合同的过程中，一方面违法行为涉嫌了刑事犯罪，是其单方行为引发的另一法律关系即刑事法律关系。处理这一法律关系时，即使责任人受到刑事责任追究，因其侵犯国家公权力而受到的惩罚后果，并不影响其与对方已形成的合同义务。在刑民交叉法律关系的处理上，不能以涉嫌犯罪或者已经生效的刑事案件的判决认定构成犯罪及刑事责任的追究来对抗、否认和免除起诉民事部分案件的民事责任。民事责任产生的原因之一是合同，该合同效力不必然无效，因为这是两个完全不同的法律关系，由此对合同效力的审查必须依据法律、法规和司法解释明文规定，更不能以刑事裁判判处了责任人的刑事责任从而作出驳回民事权利人的民事权益请求的裁判。

从民法的角度分析，当事人一方的诈骗行为，无非属于性质更加严重的欺诈。当欺诈行为的程度与结果超过了刑法容忍的限度，就陷入刑罚的调整范畴，但这并不影响民法视野下该行为仍然被认定为欺诈。认定欺诈类合同为可变更、可撤销合同，更具理论与实践意义，详言之，一是有利于保护权利人的权益，

权利人既可以选择合同有效并且继续履行合同，也可以选择变更或者撤销合同；二是有利于追究行为人的违约责任，如果认定合同无效，则违约责任也就失去了逻辑前提；三是有利于体现私法领域意思自治的基本原则。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十二条第一款的规定，借款人的借贷行为涉嫌犯罪，或者已经生效的裁判认定构成犯罪，当事人提起民事诉讼的，民间借贷合同并不当然无效。合同的效力应依据《中华人民共和国民法典》第一百四十四条、第一百四十六条、第一百五十三条、第一百五十四条以及《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》的第十三条之规定，认定民间借贷合同的效力。

编写人：广东省肇庆市中级人民法院 苏振业

借款用于偿还违法债务的效力认定及法律后果

——雷某诉王某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖南省郴州市中级人民法院(2023)湘10民终631号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):雷某

被告(上诉人):王某

【基本案情】

原、被告系朋友关系。王某从2019年开始陆续向雷某借款，并于2021年2

月26日向雷某出具一份借条，内容为：“今借到雷某现金拾万元整计(100000元)，归还日期2022年元月5日，此据为证”；于2021年4月13日向雷某出具一份借条，内容为：“今借到雷某现金伍万元整计(50000元)，归还日期2022年元月30日，此据为证”；于2021年5月7日向雷某出具一份借条，内容为：“今借到雷某现金伍万元整计(50000元)，归还日期2021年12月30日，此据为证”；以上三张借条金额合计200000元。

庭审中，原告雷某陈述，于2021年2月26日出具的借条金额100000元系先前累计借款汇总得出。被告王某陈述，对2021年4月13日、2021年5月7日两张借条上的金额50000元无异议，但认为于2021年2月26日借条上的金额100000元系原、被告双方共同买地下“六合彩”亏损的钱，由雷某直接将借款直接支付给了“六合彩”的庄家，并未经王某之手。雷某认可该两笔借款是王某购买地下“六合彩”亏损了，而根据王某的要求由雷某直接垫付给他人。同时，被告王某为证明还款，向法院提交了2019年至2022年向雷某微信以及银行转账的流水记录，拟证明原、被告之间存在多笔资金往来，其中王某于2019年向雷某还款3000元、于2020年向雷某还款19000元、于2021年向雷某还款64000元、于2022年向雷某还款32400元，以上金额共计173900元。雷某对此不予认可，称王某借款后，未向雷某偿还过借款，王某2019年至2022年转给雷某的钱是通过雷某购买地下“六合彩”，而非归还雷某借款。

【案件焦点】

案涉借款是用于偿还违法债务的是否要偿还。

【法院裁判要旨】

湖南省郴州市北湖区人民法院经审理认为：本案系民间借贷纠纷。本案中，根据出具的借条以及双方在庭审中的陈述，可以证实双方借贷关系成立。其中，被告称于2021年2月26日出具的借条金额为100000元系原、被告双方共同买“六合彩”亏损的钱，但未提供相关证据予以证明，对此不予采纳。法院认定 本案的借

款金额为200000元。根据转账流水记录，可以证实双方存在多笔资金

往来，被告王某主张在2019年至2022年期间共向原告归还了173900元借款，但被告出具的借条时间均为2021年，借条上的金额未扣除相应还款金额，明显不符合一般交易习惯，故法院对被告主张还款的事实不予采信。另外，虽然原、被告双方购买地下“六合彩”属违法行为，但双方的民间借贷关系仍应受法律保护。被告王某向原告借款后，未按约定的时间内向原告偿还借款，其行为属违约，故对原告要求被告归还借款200000元的诉讼请求，法院予以支持。

湖南省郴州市北湖区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第八条、第六百六十七条、第六百七十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，判决如下：

一、被告王某偿还原告雷某借款200000元；

二、驳回原告的其他诉讼请求。

宣判后，原告不服，提出上诉。

湖南省郴州市中级人民法院经审理认为：本案为民间借贷纠纷。二审的争议焦点为案涉三张借条载明的内容是否真实，能否认定为合法的民间借贷关系。

本案中，雷某与王某共同参与购买地下“六合彩”，亏损后，雷某明知王某借款是用于支付买码钱给“六合彩”庄家，仍同意就王某亏损部分代王某付款，之后，王某向雷某出具了落款日期为2021年4月13日和2021年5月7日的两张5万元借条。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条之规定，出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的，人民法院应当认定民间借贷合

同无效。故，依照法律规定案涉2021年4月13日和2021年5月7日的借条即民间借贷合同无效。民事法律行为虽无效，但行为人因该行为取得的财产应当予以返还。然而，根据当事人双方陈述，雷某并未将上述两张借条约定的借款直接给付王某，且雷某亦未提交证据证明其已代王某向“六合彩”庄家支付了该笔款项，因此，对于雷某主张王某归还2021年4月13日和2021年5月7日借条中约定借款的诉讼请求，不予支持。王某的这一上诉理由成立，法院予以支持。

另，关于2021年2月26日借条约定的10万元借款，王某上诉称该笔借款的实际借款金额仅为5万元，其余部分为利息，且其已经超额还款。根据一审查明的事实，2019年至2021年雷某与王某存在多笔转款，涉及金额高达50余万元。一审庭审时，雷某认可出借给王某的借款金额为20万元，王某认可收到雷某的借款金额为133500元，并当庭陈述“第一笔100000元的借款是属实的”。王某的该陈述已经构成对2021年2月26日10万元借条的自认，而王某二审提交的通话录音并不能证实该10万元借款的来龙去脉，亦不能证实其提出借款本金为5万元，其余为利息的上诉主张。此外，王某提出其在出具借条后，已陆续还款173900元，但因当事人双方转账频繁，又涉及共同参赌以及借款给案外人等事宜，无法区分每笔款项的具体用途，且王某在转账时未特别备注“还款”，亦未要求雷某更换借据，与常理不符，因此，对王某的该项上诉主张，不予支持。综上所述，王某的上诉请求部分成立。

湖南省郴州市中级人民法院依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、撤销一审民事判决；
- 二、上诉人王某向被上诉人雷某偿还借款100000元；
- 三、驳回上诉人王某的其他上诉请求。

【法官后语】

本案是关于借款用于违法活动所涉及的相关法律问题，现就两个主要问题进行阐述：

一、因偿还赌债而签订的借款合同是否有效

第一种意见认为，出借人出借资金给借款人，用于偿还赌债，借款人借款目的非法，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第四项的规定，出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。

第二种意见认为，出借人在出借资金前，虽已知晓借款人将用所借资金用

于偿还赌债，但法律禁止的是出借人将资金出借给借款人用于违法用途，并未禁止出借人将资金出借给借款人用于偿还其从事违法活动所欠的债务，两者有根本区别，出借人的出借行为并不违反法律规定，借款人和出借人之间的借贷关系合法有效，借款人应承担还款义务。重点在于，借款人所借款项并非直接用于赌博，而是用于偿还赌博所欠之债，其为偿还赌债而借款的目的是否属于法律规定的用于违法犯罪活动。

目前司法实践采纳第一种意见。首先，何为非法目的？违反法律、行政法规强制性规定的民事法律行为欲达到之目的，即为非法目的。我国法律法规明文规定禁止从事赌博活动，当事人为赌博而借款，其借款合同当然无效。从事赌博活动所欠之债，因其先前行为非法，所欠之债属于非法之债，借款人明知他人为偿还赌债而出借资金，虽采取借条的合法形式，但属于以合法形式掩盖非法目的，“恶债非法”，根据最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条，具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：……（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的。第二种意见认为借款用途的非法性仅限于因赌博等非法活动而形成的借贷关系，缩小的非法性的概念，以偏概全。其次，最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定，具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：……（六）违背公序良俗的。出借人明知借款人借款用于偿还赌债，仍为其提供资金，间接为借款人赌博的非法活动提供了便利，出借人的借款行为不仅应得到法律直接否定，还违背了公序良俗原则，恶俗亦非法，亦不能得到肯定的评价，借款人明知其出借资金用于偿还赌债，实际上出借人的行为性质为一种违法或犯罪的帮助行为。如肯定，会使得赌博人员赌资来源的渠道更加宽大，导致催生更多的赌博犯罪活动借款用途的合法性，是借贷法律关系的根本，违反法律、行政法规的效力性规定或公序良俗原则，将会导致借款合同行为无效，出借人应在出借资金前对借款人的借款用途尽到审慎义务，如借款人将借款用于非法目的，应拒绝出借资金。

二、合同被认定无效后的民事法律后果

第一种意见认为，出借人明知借款人将所借款项用于从事赌博活动，仍然提供借款，属于非法债务，依法不受法律保护，出借人起诉要求借款人偿还借款的诉求应全部驳回。

第二种意见认为，出借人明知借款人将所借款项用于赌博的民间借贷合同应为无效，基于合同无效法律后果的规定，借款人应将借款本金返还出借人，同时因出借人自身具有明显过错，其无权向借款人主张违约金、利息等。

笔者同意第二种观点。《中华人民共和国民法典》对合同无效的法律后果作出明确规定，合同无效后应按因合同取得的财产应当返还的法律规定进行处理。理由如下：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第四项规定“出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的”，民间借贷合同无效。对此，《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。故出借人明知借款人将所借款项用于赌博的民间借贷行为无效，根据上述法律规定借款人应返还借款本金，同时出借人明知借款人将借款用于赌博仍出借，存在明显过错，其无权主张违约金及利息等。此外，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第二款规定，违背公序良俗的民事法律行为无效，即使明知借款用于赌博的民间借

贷行为认定有 违公序良俗，同样是合同无效的法律后果，亦应按《中华人民共和国民法典》

第一百五十七条规定进行处理。有人可能会担心，民间借贷无效仍然要求借款人返还借款本金，是否会助长赌博这一违法犯罪活动？笔者认为上述讨论的仅是民间借贷无效的民事处理方式，不妨碍公安机关依据法院查明的事实对赌博 违法行为进行查处，这本身就是对借贷双方有力的法律惩戒。

编写人：湖南省郴州市北湖区人民法院 陈安波 刘 斌

民间借贷套取金融机构借款转贷无效的清算返还规则

——李某诉刘某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院(2023)新0104民初8854号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：李某

被告：刘某某

【基本案情】

2017年9月13日，李某向刘某某转账提供借款40000元，还从银行贷款转贷给刘某某。2020年7月2日，经结算双方签订《借款协议》：“出借人向借款人提供借款资金人民币120876.22元；出借人为给借款人提供贷款，于2018年9月11日向银行申请分期通小额贷款业务，贷款年利率4.5%，截至2020年7月1日，共有本金98175元，借款人知晓该笔借款的所有约定。剩余22701.22元为出借人自有资金。借款资金共计120876.22元。上述所有款项由借款人持有且由其实际使用；本协议项下借款本息采用以下方式归还：98175元，每月以相等的额度偿还借款本息，每月3175元，还款日为每月六号。出借人、借款人约定于2020年12月30日前一次性还清。”2022年9月起，因刘某某未依约还款，李某自行向银行还款合计37900元。李某诉至法院，请求判令：刘某某

偿还借款及利息37900元。

【案件焦点】

案涉民间借贷无效部分如何清算返还。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院经审理认为：李某自认未偿还的借款系从银行贷款后转借给刘某某，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第一项的规定，套取金融机构贷款转贷的，人民法院应当认定民间借贷合同为无效。故该部分借贷应为无效。而对于合同无效后财产返还及损失赔偿的问题，应当适用《中华人民共和国民法总则》第一百五十七条，但该条并未区分合同无效的类型、当事人的过错程度进行具体规定。法院认为，为引导当事人从正规金融渠道融资，威慑自金融机构贷款后转贷及借款行为，对该问题应以借贷双方均不得从无效合同中获益为导向处理。具体而言，案涉《借款协议》无效，刘某某不应只偿还李某借款本金和按照贷款市场报价利率计算的利息，还应当偿清李某给银行偿还的借款本金及利息，否则刘某某将因合同无效反而获得偿还较少利息的利益；与此同时，李某偿清借款本金及利息后，刘某某也不应按照双方约定，而应按照贷款市场报价利率支付利息。故法院对李某的诉请应予支持。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的规定》第一条第二款，《中华人民共和国民法总则》第一百五十七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、第一百六十五条的规定，作出如下判决：

一、被告刘某某于本判决生效之日起十日内支付原告李某借款本金及利息37900元；

二、驳回原告李某的其他诉讼请求。

本案适用小额诉讼程序审理，宣判后现判决已发生法律效力。

【法官后语】

因合同无效清算不适用得利丧失抗辩，审判实践中对于民间借贷中套取金融机构贷款转贷无效的清算返还，不适用《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第九百八十五条关于不当得利返还的规定，而应适用《民法典》第一百五十七条无效合同清算的一般规则，并无疑义。但实证研究表明，目前的裁判大多固守判决贷款本金和以贷款市场报价利率计算利息的思路。此从法教义学的内部视角看有悖于《民法典》第一百五十七条的规范意旨，从利益衡量的外部视角看也不能发挥引导当事人从正规渠道融资的效果，应予摒弃。

一、内部视角：《民法典》第一百五十七条的规范意旨

（一）规范目的

《民法典》第一百五十七条是合同无效清算返还的一般规则，其规范目的在于“让双方当事人的财产情况恢复到如同没有订立合同的状态”。具体到民间借贷中套取金融机构贷款转贷无效的清算返还，由于套贷后转贷本质上是一种信用出借行为，只有借款人承担“如同向金融机构借款”的还款责任，才能实现该条的规范意旨。一般而言，金融机构的贷款利息高于贷款市场的报价利率，可能还包括手续费、逾期罚息等，判决出借人仅承担借款本金和贷款市场报价利率的利息，显然不妥。

（二）“过错”的认定

此种判决的裁判依据常为《民法典》第一百五十七条——“有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任”——的规定，这也是对

《民法典》第一百五十七条的误读。首先，“有过 错”不是指出借人或者借款人明知或者应当知道合同无效。“任何人均不得以 不知法律有规定或者宣称对法律有不同理解而免于适用该法律”，如将出借人 的转贷行为解释为明知或应知该合同无效而为之，从而认定出借人有过错，则 无法解释其不明知或应知的情形为何。其次，学界对于前述责任为缔约过失责 任已达成共识。通说认为，缔约过失责任制度源于“当事人为了订立合同而接 触或者磋商时，虽然合同尚未成立，但是根据诚信信用原则，任何一方当事人

均负有协助、照顾、保护、重视、通知、保密等先合同义务”，“有过错”是指行为人在无效合同订立过程中有违诚信的行为。因此，合同无效本身不产生损害赔偿，违反先合同义务（诚信原则）才会产生。最后，合同无效型缔约过失责任是非常少见的，韩世远教授即认为“现在生活中，合同无效的缔约过失责任是非常少见的；而大量存在的，则是合同有效型的缔约过失问题”，目前裁判中以出借人有过错为由，动辄适用《民法典》第一百五十七条，判决借款人只承担借款本金和以贷款市场报价利率计算的利息，无疑是错误的。

二、外部视角：不同裁判的利益衡量

司法不仅要求形式上的法治，还要求在法律解释过程中将后果考量作为一种论证方法容纳进来，以实现法律效果、社会效果和政治效果的统一。就本文讨论的问题而言，目前的类案大多判决借款人只承担借款本金和以贷款市场报价利率计算的利息，而本案判决借款人承担出借人偿还银行的借款本息之和。从利益衡量的角度对比两种裁判的后果如下：

（一）借贷双方的利益

从出借人和借款人群体的利益看，后者不仅当然有利于出借人，从长远看也有利于借款人。与商事借贷以财产登记为信用不同，民间借贷以熟人社会的信息为信用，其本质是交易模式与信用识别和资金供需的矛盾。在民间借贷资金本就供需失衡的情况下，若按前者判决将使借款人群体的融资更为困难。

（二）金融机构的利益

从金融机构的利益看，套取金融机构借款后转贷本质上是出借信用的行为，若按前者判决，则相当于本没有信用获得金融机构贷款的借款人，不仅获得了贷款还只需承担较低的利息，这显然与金融机构的利益不符。

（三）社会公共利益

从社会公共利益看，前者判决将可能使追逐自身利益的借款人为偿还较少的利息，故意不偿还借款，传递出违约方反倒从无效合同中获益的价值导向，严重违反诚信原则，有损于社会公共利益。

